

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA V

RELEMBRANDO

“Somente por lei específica” vale para toda a Administração indireta.

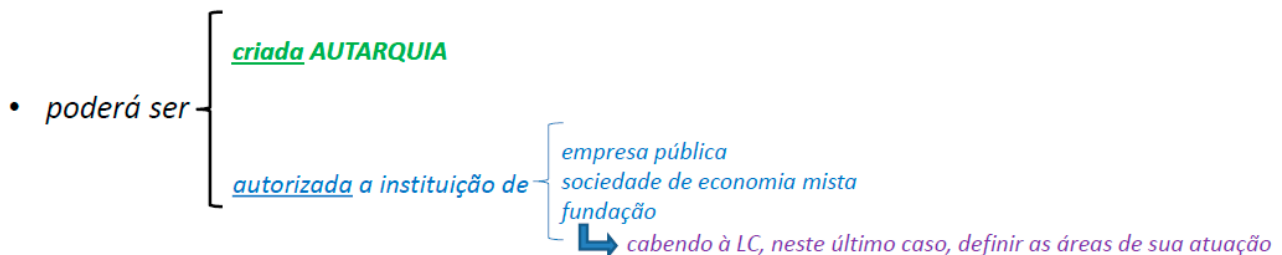
Criação das entidades da Administração Indireta

CF/88

Art. 37, XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

- Somente;
- Por lei;
- Específica;
- Poderá ser.

A partir de agora, haverá uma separação, colocando regras para umas distintas de outras:



Como visto anteriormente, observa-se que há a divisão em dois blocos: autarquias e as demais.

Qualquer entidade que integra a Administração indireta, seja ela de direito público, seja de direito privado, depende de lei para ser criada?

De acordo com o artigo 37, XIX, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação.

Apalavra instituição significa criação. Dessa forma, todas elas (autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista), dependem de lei para serem criadas.

- Não é possível criar uma autarquia sem que haja lei anterior;



5m

ANOTAÇÕES

- Não é possível criar uma empresa pública sem que haja lei anterior;
- Não é possível criar uma fundação sem que haja lei anterior;
- Não é possível criar uma sociedade de economia mista sem que haja lei anterior.

Quando a CF dispõe que “poderá ser criada autarquia”, isso significa dizer que a própria lei já cria, ao passo que quando ela dispõe “autorizada a criação/instituição”, ela está informando que a lei autoriza, mas a criação ocorrerá depois.

Em virtude de a autarquia ser uma PJ de direito público, a própria lei já a cria, sem necessidade de registro. Isso acontece juridicamente falando, ou seja, mesmo que ainda não haja o prédio, os servidores, a localização, se a lei estipula, ela já está criada.

No tocante às demais, deverá nascer uma lei que autorize, por esse motivo, a CF dispõe que “autorizada a instituição”. Sempre que nos depararmos com construções do tipo “depende de autorização legislativa” ou “após lei autorizando” no texto constitucional, significa que primeiro vem a lei que determina que pode fazer, isto é, não é ela quem cria, mas precisa autorizar.

Elas só serão efetivamente criadas com o registro dos seus atos constitutivos. O registro é um ato privado de efetivação do nascimento.

Especificamente no tocante à fundação, a CF dispõe o seguinte “cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. Isso significa que a lei complementar apenas definirá a área de atuação, isto é, não vai criar nem autorizar. Por exemplo, as fundações atuarão nas áreas sociais, mas quais áreas? A lei complementar deverá definir/delimitar isso.

ATENÇÃO

Quando a CF nasceu, em 5 de outubro de 1988, não havia a diferenciação entre criar e autorizar, ela apenas determinava que “a lei criará autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública”. Em 1998, a CF foi alterada no referido ponto, ficando com a redação que conhecemos.

Ocorre que a fundação pode ser de direito público ou de direito privado, então, a doutrina interpreta a regra da seguinte maneira: a fundação disposta no artigo é a fundação pública, visto que faz parte da Administração Pública, mas é uma fundação pública de direito privado. Isto é: a fundação pública de direito privado é que precisa ser autorizada.

ANOTAÇÕES

Isso porque, junto com as autarquias, existem as fundações públicas de direito público. Em outras palavras, a doutrina entende que as chamadas fundações públicas de direito público são, na verdade, espécies de autarquias.

Por exemplo, quando se fala da FUNAI ou da UnB, que são fundações públicas de direito público, é a mesma coisa de falar-se em autarquia, inclusive, elas são chamadas de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas.

Quando se fala em fundação pública de direito público, é autarquia; se ela é uma autarquia, logo, ela é criada por lei. Então, quanto à fundação pública de direito público, fala-se da criação pela própria lei; já a fundação pública de direito privado é, de fato, autorizada.

Obs.: apesar de ser um tema complicado, a incidência em provas é relativamente baixa.



O PULO DO GATO

Se a prova colocar apenas o termo “fundação”, que é o que está escrito na CF, que não fez diferenciação, deverá ser autorizada.

Se a prova colocar “fundação pública”, será preciso manter o raciocínio de que ela é autorizada, visto que chamar uma fundação de pública é apenas dizer que ela é uma fundação governamental, ou seja, que ela integra a estrutura da Administração Pública. Não está sendo dada, ainda, a personalidade de direito público ou privado.

Essas regras são as mais cobradas em provas.

O ideal seria especificar a fundação pública de direito privado (autorizada) e a fundação pública de direito público, que, por ser autarquia, é criada.

Se a prova colocar alternativas como “sempre as fundações serão criadas” ou “sempre serão autorizadas, não criadas”, estará ERRADO, pois não existe o “sempre”, elas podem ser ou criadas ou autorizadas. Nas provas, a ideia que prevalece é a de que elas são autorizadas, a não ser que seja colocada especificamente “fundação pública de direito público”.



20m

ANOTAÇÕES

Criação das subsidiárias da Administração indireta

Subsidiárias da Administração indireta são pessoas jurídicas que ficarão atreladas a uma das entidades que integram a indireta, em regra, empresa pública e sociedade de economia mista terão espécies de filiais. Juridicamente, não são propriamente filiais, embora a doutrina faça referência em paralelo, como se fossem filiais, estando ligadas à pessoa principal/central, mas com a sua autonomia.

Obs.: não é preciso se preocupar com a classificação de subsidiárias em provas, porque não cai. O que importa são as regras e, sobretudo, a criação das subsidiárias.

Exemplo:

A Petrobras é uma sociedade de economia mista que tem dezenas de subsidiárias, cada uma com uma área específica, não são propriamente filiais, mas é como se fossem. Inclusive, há divergências se as subsidiárias integram ou não a Administração.

CF/1988

Art. 37. XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.

“Depende de autorização legislativa” = depende de lei autorizando. É uma expressão muito comum na CF.

Ressalta-se que a lei apenas autoriza a criação, mas não cria.



25m

ATENÇÃO

Embora seja necessária a autorização legislativa, a lei não precisa ser específica.

Pode ser uma lei genérica autorizando a criação. Somente será necessária lei específica para a criação das especiais: autarquia, empresa pública, fundação pública e empresa de economia mista.

Além disso, uma lei específica autorizando a criação de uma empresa pública, por exemplo, também pode autorizar a criação das subsidiárias.

ANOTAÇÕES

Uma decisão recente do STF alterou algumas regras:

- **Extinção de empresa pública e sociedade de economia mista** (ADI 6241 – STF – 05/02/21)

- Até alguns cursos anteriores, utilizava-se a seguinte regra:

Há uma simetria/paralelismo entre criação e extinção, ou seja, a lei é exigida tanto para criar quanto para extinguir. **No entanto**, o STF, especificamente no tocante às empresas públicas e sociedades de economia mista, entendeu o seguinte:

- **Regra:** autorização legislativa genérica (não precisa ser específica).

Até agora, foi estudado que era necessária a lei específica para a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista, e o STF vem e determina que, para **EXTINGUIR**, não precisa ser específica, podendo ser genérica.

- Não corresponde à delegação discricionária e arbitrária ao Chefe do Poder Executivo.
 - Não significa que, a partir de agora, o Chefe do Executivo poderá extinguir como bem entender, pois continua exigindo uma lei que autorize.
- Deve ser pautada em objetivos e princípios que têm de ser observados nas diversas fases do processo de desestatização.
 - **Exceção: nos casos das estatais cuja lei instituidora tenha previsto, expressamente, a necessidade de lei específica para sua extinção ou privatização, é necessário que o administrador público observe a norma legal.**

Se a lei específica que autorizou a criação determinar que depende de lei específica para sua extinção, deverá se respeitar o paralelismo. Caso não haja especificação, a lei poderá ser genérica.

Obs.: a exigência de autorização legislativa não se aplica à venda do controle das subsidiárias e controladas de empresas públicas e sociedades de economia mista. Não há necessidade de licitação, desde que siga procedimento que observe os princípios da Administração Pública (ADI 5264).

ANOTAÇÕES

Em relação à extinção das empresas públicas e sociedades de economia mista, há necessidade de lei autorizando; tal lei não precisa ser específica, podendo ser genérica. Se a lei específica que autorizou a criação determinar que depende de lei específica para sua extinção, deverá se respeitar o paralelismo. Caso não haja especificação, a lei poderá ser genérica.

Já as subsidiárias dependem de lei autorizando a sua criação, tal lei também não precisa ser específica. Quanto à sua extinção, o STF, em julgado anterior, determinou que “a exigência de autorização legislativa não se aplica à venda do controle das subsidiárias e controladas de empresas públicas e sociedades de economia mista”, ou seja, para extinguir ou vender uma subsidiária, não haverá necessidade de lei nem de licitação, desde que “siga procedimento que observe os princípios da Administração Pública”.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2019/TCE-RO/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS) A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), sociedade de economia mista estadual, valendo-se de permissão genérica constante do ato normativo que autorizou sua criação, instituiu uma empresa subsidiária integral com o objetivo de desenvolver pesquisas para melhorar o abastecimento de água no estado. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, caso deseje alienar o controle acionário da subsidiária integral, o estado de Rondônia
 - a. Deverá obter autorização legislativa e proceder à licitação.
 - b. Deverá obter autorização legislativa, sendo dispensável a licitação, desde que observados os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição Federal de 1988.
 - c. Não precisará obter autorização legislativa, mas será necessária a licitação na modalidade concorrência.
 - d. Não precisará obter autorização legislativa, podendo realizar a alienação sem licitação, desde que se observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade.
 - e. Não precisará obter autorização legislativa, podendo a alienação ser realizada sem licitação e sem qualquer condicionante.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Alienar é uma forma de privatizar, que é uma forma de extinguir.

a) Não precisa nem de autorização legislativa nem de licitação.

b) Não precisa de autorização legislativa.

c) Não há necessidade de licitação.

De fato, não precisará obter autorização legislativa, podendo realizar a alienação sem licitação, desde que se observem os princípios da Administração Pública inscritos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade.

Não precisará obter autorização legislativa, podendo a alienação ser realizada sem licitação, mas deverá observar os princípios do art. 37 da CF/1988.

Resumo para resolução da questão:

- i) a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação; e
- ii) a exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no art. 37 da Constituição, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade

Resumo das características, criação e extinção das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
	Autarquia	Fundação Pública		Empresa Pública	S.E.M
Personalidade Jurídica	Direito Público	Dir. Público	Dir. Privado	Direito Privado	Direito Privado
Atividades	Típicas de Estado	Sociais	Sociais	Econômicas (Serviço Público*)	Econômicas (Serviço Público*)
Prestação da atividade	Descentralização por outorga (funcional, por serviços ou técnica)				
Criação	Lei específica (diretamente)	Lei específica (diretamente)	Lei apenas autoriza (a criação se dá depois)	Lei específica apenas autoriza (a criação se dá depois)	Lei específica apenas autoriza (a criação se dá depois)
Extinção	Lei específica (diretamente)	Lei específica (diretamente)	Lei específica autoriza	Lei autoriza ("genérica" ou específica)*	Lei autoriza ("genérica" ou específica)*

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. d.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
